

1500130-24.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOCIMAR DAL CHIAVON

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... evidenciada a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes impõe-se a absolvição do réu por falta de provas com base no 386 VII do Código de Processo Penal, caso não for este o entendimento o que não se espera que ocorra à desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/2006, não há provas de que a substância era sua e era para o tráfico. Deve ser aplicada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

1ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Centro, Itararé - 18460-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500130-24.2022.8.26.0622

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2108979/2022 - DEL.POL.ITARARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA e outro

Artigo da Denúncia:

Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06

Réu Preso

Aos 21 de outubro de 2022, às 13:32h, em razão da pandemia da Covid-19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Instrução e Julgamento - 1ª Vara de Itararé-SP - Processo nº 1500130-24.2022.8.26.0622 - réu: DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA, RG 71.252.900, 21/10/2022, 13:30h", sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. JOCIMAR DAL CHIAVON, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Thiago Gatti Fernandes, DD. Promotor de Justiça; do réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva, preso no Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César-SP; do réu Chayton Luan de Jesus; dos Defensores dos réus, Dr. Junieber Ramos dos Santos, OAB 441999/SP; e Dra. Kelly Paloma Garcia Weiss, OAB 386360/SP; das testemunhas arroladas: João Paulo Coutinho e Juliano Dias Junior. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva e seu Defensor conversa privativa, por meio da funcionalidade de criação de salas do Microsoft Teams. A seguir, foi oportunizado ao réu Chayton Luan de Jesus e sua Defensora conversa privativa, tendo o Meritíssimo Juiz e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. Ato contínuo, retornando o Magistrado e demais participantes à sala virtual, bem como o Defensor e o réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva à sala

principal, procedeu-se ao início da audiência virtual, oportunidade em que a testemunha João Paulo Coutinho foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, a qual prestou depoimento e, em seguida, foi desconectada da audiência virtual. Na sequência, a testemunha Juliano Dias Junior foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, a qual prestou depoimento e, em seguida, foi desconectada da audiência virtual. Após, o Meritíssimo Juiz questionou aos réus se desejavam ter nova entrevista com seus Defensores antes do interrogatório, os quais responderam negativamente. Em seguida, o Meritíssimo Juiz determinou que o réu Chayton Luan de Jesus deixasse momentaneamente o ambiente virtual, a fim de interrogar o réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva, o que, em seguida, foi feito por ele. Na sequência, o réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva foi interrogado. Em seguida, o réu Chayton Luan de Jesus foi, novamente, adicionado, a partir do lobby, à audiência virtual e foi interrogado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo e gravados através do Microsoft Teams e ficarão armazenados em nuvem através do sistema One Drive e, posteriormente, serão importados ao sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o Meritíssimo Juiz declarou encerrada a instrução, determinando-se que se passassem às alegações finais. Ato contínuo, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida, em suma, a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, por estarem presentes a materialidade delitiva e a comprovação da autoria, bem como a decretação da prisão de Chayton Luan de Jesus e a manutenção da prisão preventiva de Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, pela Defesa do réu Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva foi requerida, em suma, a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, foi requerida a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, pela Defesa do réu Chayton Luan de Jesus foi dito: “MM. JUIZ: Segundo consta na denúncia, no dia 21 Abril de 2022, por volta das 17:30, na Rodovia SP 281, altura do Km 8, no Bairro Cerrado, nesta cidade de Itararé, os denunciados DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA e CHAYTON LUAN DE JESUS supostamente teriam transportado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar substância ilícita, sendo assim, estariam supostamente incurso no artigo 33, “caput” da lei 11.343/06. Ocorre que Chayton conforme informou em solo policial é usuário de cocaína e na data dos fatos foi juntamente com DOUGLAS buscar droga para o uso, durante a instrução Chayton afirmou que as drogas eram para Douglas e que não haveria informado antes devido a ter medo deste. Em momento algum ficou comprovado à traficância, nem provas seguras que realmente era toda a droga de CHAYTON, a dúvida sempre beneficia o acusado, dessa forma a absolvição quanto ao delito ou deve ocorrer à desclassificação do tipo penal para o artigo 28 da lei 11.343/2006, sendo que na data dos fatos embora fosse transportada substância ilícita essa era para seu uso. POSTO ISTO, espera a defesa que em relação ao denunciado CHAYTON LUAN DE JESUS não estando evidenciada a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes impõe-se a absolvição do réu por falta de provas com base no 386 VII do Código de Processo Penal, caso não for este o entendimento o que não se espera que ocorra à desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/2006, não há provas de que a substância era sua e era para o tráfico. Deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea conforme artigo 65, inciso III, alínea D do Código Penal. Caso não for este o entendimento o que não se espera que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, ocorrendo à redução da pena do denunciado, sendo que o agente não se dedica atividades criminosas nem integra organização criminosa, a vedação a restritiva de direitos

foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 97.256/RS, sendo assim, que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos com base no art.44, inciso III, uma vez que as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente, em caso de condenação que seja lhe dado o direito de recorrer em liberdade". Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA e CHAYTON LUAN DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 17h30min, na Rodovia SP 281, altura do Km 8, no Bairro Cerrado, nesta cidade de Itararé, um aderindo conscientemente à vontade do outro, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, "cocaína" com peso de 79,71g, tudo conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); auto de constatação preliminar (fls. 19) e laudo toxicológico (fls. 89/92). Os acusados foram notificados (fls. 241) e apresentaram defesa prévia (fls. 215/218 e 246/247). A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 250/251). Os acusados foram citados (fls. 310 e 312). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os acusados foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, sendo que a acusação pugnou pela condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A Defesa do réu DOUGLAS, por seu turno, postulou pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A Defesa do réu Chayton, de mesmo modo, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, é de se assinalar não padecer a denúncia de inaptidão, uma vez que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permite, com a descrição do crime e de todas as suas circunstâncias, a mais ampla defesa. Na espécie, examinando-se atentamente a peça acusatória, dela se podem extrair os requisitos elencados por lei, tendo sido descritos os fatos imputados aos acusados, com toda sua dinâmica. A denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, plenamente válida, eis que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, incluindo, ainda, a classificação do delito, os documentos que embasaram a denúncia e o rol de testemunhas, permitindo aos acusados, dessa forma, a compreensão dos fatos criminosos cuja prática lhe foi atribuída e o pleno exercício do direito de defesa. Conforme é cediço, somente se reconhece a inépcia da denúncia quando o prejuízo à defesa for inequívoco, não permitindo a compreensão da acusação, o que, frise-se, não ocorre no caso vertente. Na hipótese, a denúncia oferecida descreveu satisfatoriamente os elementos e circunstâncias necessários à promoção da ação penal, permitindo a plena defesa e participação da Defesa na produção das provas, sem entraves. Convém sublinhar que "Descrevendo a denúncia fato típico e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP, com apoio em elementos informativos que a instruíram, é de se rejeitar a alegação de inépcia, assim como a de falta de justa causa para a ação penal, sobretudo em se verificando que o denunciado pôde se defender amplamente e que a instrução judicial ensejará melhor apreciação dos elementos configuradores do delito" (STF - HC j. 28.11.95 Rel. SYDNEY SANCHES, JSTFLEX 214/341); "Se a denúncia narra fato que permite adequação típica, ela não é, formalmente, inepta (art. 41 do CPP)" (STJ - Resp. 23.9.97 Rel. FÉLIX FISCHER, JSTJ 105/303); "Inadmissível o trancamento da ação penal se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP com a exposição do fato criminoso, permitindo o exercício da ampla defesa. II Inconsistência da alegação de inépcia" (STJ- RHC, j. 7.6.94 Rel. ANSELMO SANTIAGO, JSTJ 70/341); "Descabe a alegação de inépcia da denúncia quando esta narra os fatos delituosos e atende, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando a ampla defesa do acusado" (STJ - RHC- Rel. ANSELMO SANTIAGO, RSTJ 75/115); "Não é inepta a peça acusatória que preenche todos os requisitos exigidos no art. 41 do CPP. Qualquer omissão relativa a circunstâncias periféricas não impossibilita o juízo de admissibilidade, já que não

impede o amplo exercício de defesa" (TRF- 1ª Reg. HC j. 17.10.95 Rel. SINVAL ANTUNES, JSTJ 80/511) (WILSON NINNO, in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, coord. ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, vol. 1/1029, n. 2.02, 7ª edição). Nesses termos, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela Defesa. No mérito, a presente ação penal é procedente. A materialidade do delito descrito veio comprovada, dentre outros, pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (fls. 14/16 e 150/), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19), rebatimentos fotográficos (fls. 23/24), laudo pericial (fls. 89/92), e pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também é certa e recai sobre os acusados. A testemunha João Paulo Coutinho declarou em Juízo: "A equipe realizava fiscalização de trânsito quando avistamos o veículo, vimos a atitude dos dois indivíduos, foi possível visualizar jogar sacola. A gente continuou a abordagem já na saída. Foi feita a abordagem, ambos foram questionados sobre o que haviam jogado. (...). Vimos que eles não tinham nada no momento, foram liberados. Voltamos, observamos a sacola, tentamos abordar. Abordamos, Chayton se evadiu. Morita confessou que havia droga no veículo e que era do Chayton. Sim, eram os dois indivíduos que estavam no veículo. Foi possível, porque quando ele passou pela viatura, o veículo passou devagar na lombada, foi possível visualizar os dois. O Douglas já tinha abordado na cidade de Taquarituba, só foi localizada esta. Chayton não conhecia pessoalmente. Foi dispensada do lado direito do passageiro. Tava o Chayton, Douglas era que dirigia o veículo. Uma outra equipe apoiou a abordagem, pedimos apoio de todas as equipes da região. Douglas tava dirigindo. O carro tava sem combustível. Ele não se entregou. A namorada dele levou combustível. A droga era do Chayton. Douglas sabia. Chayton jogou, inclusive falou pra ele que tinha perdido o dinheiro da droga. Sim, na delegacia, a gente pediu pra ele mostrar o aparelho, ele quebrou na frente nossa o aparelho. Ela tava num formato de pó, porém tinha umas pedras. Não foi possível verificar o celular, não verificamos nada. Isso, ela foi feito em primeiro momento, só que a gente tava distante da onde a droga tava. Pra ir até a droga teria que deixar um policial em número inferior, por estar dois indivíduos presos. (...). Foram averiguados os documentos. Fizemos teste de etilômetro. Ele não dificultou o trabalho dos policiais. No vidro do lado direito, no caso no vidro do passageiro. Douglas desde a hora que a gente chegou lá ele foi bem tranquilo, ele colaborou e falou toda a verdade. Não foi encontrado nada com ele. Chayton não. A consulta foi feita através do banco nacional. Já o conhecia. Não tenho dúvida. Douglas confirmou que era ele também. Era cocaína. Estava em formato de pedras, foi aproximadamente menos de cem gramas. Não me recordo o local. Não mencionou se já tinha feito esse transporte". A testemunha Juliano Dias Junior declarou em Juízo: "No dia dos fatos, tava fazendo fiscalização de trânsito, o veículo passou, o colega pediu pra gente abordar. Na curva a gente viu ser arremessado sacola branca. O veículo foi abordado. Não tinha nada de ilícito quanto aos documentos. Não tinha apoio, a gente retornou pra ver o que foi arremessada pela janela. Ela rasgou, tava com substância de pó branco. A gente foi atrás do veículo de novo, porém o veículo se evadiu, a gente pediu apoio, conseguiu abordar o veículo. Quando a nossa viatura chegou, só tava o condutor, o passageiro tinha se evadido. O condutor disse que o conteúdo da sacola era do passageiro. Apenas tinha pegado o passageiro e tinha levado pra cidade de Itararé. O condutor sabia que tava transportando, ele declarou que certa quantidade seria pra consumo pessoal. Não conhecia eles. Não havia denúncias. Não conhecia. Foi do passageiro que foi arremessada a droga. Exatamente, pegaram de Itararé e iam levar pra Riversul. Foi na delegacia, o escrivão pediu pra ele desbloquear o celular, daí ele quebrou o celular. Segundo o relato dele, o carro teve pane seca. Não conhecia Chayton. Não só por foto mesmo. A gente procurou nas redes alguma foto para localização posterior. Na delegacia, a gente descobriu que os fazendeiros localizaram o Chayton. Ele não tava mais no local. Isso, segundo a declaração dele, foi isso aí. Foi arremessada pela janela do carona. Douglas não tentou dificultar o trabalho, ele permaneceu no local. Com Douglas, não foi encontrado. Era Chayton, o passageiro". O acusado Douglas Adriano Mitsuo Morita Nunes da Silva, em seu interrogatório judicial, disse: "Não, esse fato em Riversul. Eu tava em Riversul na

casa da minha namorada, Chayton mora em Riversul. Tinha brigado com ela e fui na casa de Riversul pegar droga. Ele disse que não tinha. Fui no posto abastecer o carro, ele foi no bar pegou dinheiro. Passemos a lombada, os rodoviários vieram atrás, puxei o cinto, ele joga uma sacola pra janela, ele falou pra ir embora. Eles abordou nois, procuraram tudo no meu carro, liberaram eu. Chayton tava nervoso porque tinha perdido mil real. Eu nem sabia que ele tava com droga. Quase chegando em Riversul, acabou a gasolina, entrei na estradinha, os rodoviários tava vindo atrás. Eles foram pro meio do mato. Eu falei que não tinha droga, eu dei carona pra ele, nem sabia que ia buscar droga. Era uma quinta feriado. (...). Tinha cinquenta reais, fui na casa dele pegar droga, ele disse que ia chegar a droga na casa dele mais tarde. Fui com Chayton porque ele ia receber dinheiro. Ele abasteceu cinquenta reais para eu pegar droga. Eu só tinha cinquenta reais, ia receber em droga. Foi bem na hora que puxei o cinto de segurança. Quebrei meu celular. Eles ficaram bravo porque quebrei o celular. Isso era os cinquenta reais. Não sabia que tava indo buscar. Já tinha brigado com minha mulher, por isso que fui com ele. Ia voltar pra Riversul. Quando uso droga eu não fico na cidade. Já tinha pegado droga já. Em nenhum momento ele falou que ia buscar droga. Eu sabia a partir do momento que do dinheiro. Foi tentativa de homicídio. Já conhecia ele das biqueira. Já comprava droga dele. (...). Eu dei carona para o Chayton, não sabia que ele ia buscar droga. Deixei ele na viela. Isso foi umas quatro horas, quatro e meia da tarde. (...). Sim, sou usuário, mais de dez anos que uso drogas. Não vi que ele tava com droga escondida. Eles abordaram tranquilo, revistaram, liberaram nois na primeira abordagem. Quando puxei o cinto de segurança, ele pegou e jogou a sacola, nem sabia o que tinha na sacola. Quando deu pane no carro, o carro foi no embalo. Nisso que foi no embalo, a polícia já tava vindo, Chayton empreendeu fuga. Podia fugir, mas não tinha por que fugir. Quebrei o celular porque tem foto íntima da minha esposa. Não ia desbloquear celular sem autorização da justiça. Não tive envolvimento com tráfico. Não sabia que tava com droga. (...). O acusado Chayton Luan de Jesus, em seu interrogatório judicial, disse: "Douglas me chamou em casa, pra ir lá em Itararé pegar droga, dei cinquenta reais pra pegar droga. Os policiais enquadraram, fiquei com medo e corri. Tinha medo dele. Douglas foi na minha casa me chamar, em Riversul. Não tinha droga. Chamou pra ir lá buscar em Itararé. Douglas que me convidou. Tinha visto ele já. Não tinha feito negociação de drogas. Ele veio na minha casa me chamar pra ir junto com ele, dei cinquenta reais pra ele pra ele usar. Pra ele por a gasolina. Ia pegar cinquenta real de drogas sabe. Ele que me deu o dinheiro pra mim ir lá buscar. Quantos eu não sabia quanto que era. Eu só peguei e dei o dinheiro e vim com a droga pra ele. Não tinha ido lá, era a primeira vez. Daí os policiais mandou ele parar, daí ele me deu a droga pra mim jogar pela janela. Tava com ele a droga, tava no banco assim sabe, daí ele mandou eu jogar a droga. Daí os policiais veio e revistaram, não tinha nada, daí eles revistaram. Acabou a gasolina, fiquei com medo e corri daí. Não tinha feito o transporte. Não vendo droga. Trabalho no pinu. Eles vieram e jogaram essa droga. (...). Foi em Riversul, os policiais chegaram agredindo, falaram que a droga era minha. Tinha medo dele sabe, daí depois fiquei com medo dele fazer alguma coisa pra mim. Só vi ele uma vez assim, ia usar sabe. Ia usar pinu. Mas, agora arrumei mulher, criei juízo, vai vim filho, sosseguei". Como se vê, as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação dos acusados pelo delito descrito na denúncia.

Importante ressaltar que as testemunhas João

Paulo Coutinho e Juliano Dias Júnior apresentaram versão harmônica entre si e com as declarações prestadas em solo policial. Nada há nos autos que eles tivessem qualquer interesse em incriminar falsamente os acusados, motivo pelo qual as declarações do agente estatal têm ampla eficácia probatória. E nesse sentido: "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas –

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96 p. 39.846). Por sua vez, o acusado Chayton Luan de Jesus, em seu interrogatório judicial, admitiu o transporte das drogas apreendidas, afirmando, contudo, que elas destinavam-se ao seu consumo pessoal. O acusado Douglas negou a prática do delito, afirmando que não sabia da existência das drogas. A negativa dos acusados quanto a tráfico de drogas não convence, mormente porque isoladas do conjunto probatório, constituído principalmente pelos depoimentos do policial prestados em sede inquisitiva e em Juízo, que, em uníssono, revelaram como se deu a prisão dos acusados e a apreensão de entorpecente. É importante registrar que o acusado Chayton afirmou em seu interrogatório que o acusado Douglas o convidou para se dirigir até o Município de Itararé para adquirir drogas, assim como confirmou que arremessou o entorpecente na via pública quando percebeu que os policiais militares rodoviários os abordariam, o que não deixa qualquer dúvida a respeito da ciência do acusado Douglas a respeito do transporte das drogas. Tanto é assim, que Douglas admite que receberia parte da droga como pagamento em razão do valor gasto com o abastecimento do veículo. De outro lado, como já dito, firmes e insuspeitos, os depoimentos dos policiais, devido à ausência de indício de ilegalidade, abuso de poder ou distorção da realidade dos fatos, constituem importante elemento de convicção. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. Frente a tão robusto conjunto probatório, constata-se facilmente que os acusados, no exercício do direito à ampla defesa, buscaram se esquivar da imputação, criando versão inverossímil e isolada da verdade que emerge da prova produzida. Induvidoso, enfim, o transporte/propriedade/posse do entorpecente, que, por sua quantidade e natureza, associada as circunstâncias da prisão revelam o intuito mercantil. Se não bastasse, a quantidade apreendida afasta a condição de usuário ora alegada. Frise-se que, de acordo a prova oral, a droga apreendida teria um valor aproximado de R\$ 1.000,00 (mil reais) e poderia ser fracionada em inúmeras porções menores, circunstância que também infirma a versão de porte de drogas para consumo pessoal trazida aos autos pelos acusados. Aliás, o próprio transporte intermunicipal da droga é circunstância que fragiliza a tese defensiva, eis que absolutamente incomum para um mero usuário de cocaína. Em suma, do confronto com as provas produzidas, sucumbe a versão dos acusados quanto a ausência de tráfico, tornando frágil, isto sim, a tese absolutória/desclassificatória. A prática do tráfico ilícito de drogas restou extreme de dúvida, em razão das circunstâncias da prisão, em especial da quantidade da droga apreendida, do valor pago por ela e do transporte intermunicipal da droga. De qualquer modo, a alegada condição de usuário, não raras vezes se confunde com a de traficante, na medida em que a comercialização da droga se torna meio para sustento do vício; e o vetusto argumento do uso próprio para se esquivar da caracterização da traficância não tem aptidão de afastar a responsabilização por essa conduta inequivocamente mais grave. Em outras palavras, ao viciado traficante que, surpreendido com a droga, argumenta ser usuário, além de não lograr a descaracterização do comércio ilícito, antes o confirma. Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pelas circunstâncias da diligência, na qual o ora acusado foi pilhado na posse dos entorpecentes, pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes da lei, elementos suficientes à procedência. As provas demonstram que os entorpecentes seriam destinados à circulação e não exclusivamente a consumo próprio, até porque, como dito, eventual condição de usuário não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que afasta a pretendida desclassificação. Destarte, as provas colhidas evidenciam que os acusados, um aderindo conscientemente à vontade do outro, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, "cocaína" com peso de 79,71g, tudo conforme Auto de exibição e apreensão a fls. 17/18; Auto de constatação preliminar de fls. 19 e Laudo Toxicológico de fls. 89/92. Assim, considerando as circunstâncias supracitadas, está demonstrado que as drogas encontradas destinavam-se à mercancia, ressaltando-

se que para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. A própria Lei de Drogas dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Por fim, comprovada a materialidade delitiva e autoria do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a condenação dos acusados é medida que se impõe. Passo à fixação das penas. Do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Acusado DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA: Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes, uma vez que possui condenação transitada em julgado no processo nº. 3001634-77.2013.8.26.0275, conforme certidão de folhas 278/281. As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Assim, diante de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado praticou o presente delito após condenação com trânsito em julgado no processo nº. 0000053-44.2014.8.26.0275 e antes do decurso do prazo depurador, conforme certidão de folhas 278/281, razão pela qual agravo a pena para 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Não é o caso de se aplicar a regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme condenações anteriores que se observam na certidão de folhas 278/281. Dessa forma, torno a pena definitiva para este crime em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Fixo os dias-multa no mínimo legal. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado (fls. 278/281), fixo regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º e § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal. Diante da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Pela mesma razão, impossível a concessão da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal. Do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Acusado CHAYTON LUAN DE JESUS: Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes, contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, que deixo de valorá-la, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a pena fixada na fase anterior. Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Não é o caso de se aplicar a regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A quantidade da droga apreendida (uma porção da droga conhecida como cocaína, perfazendo o peso de 79,71g), o fato de tratar-se de transporte intermunicipal de drogas, o valor pago pela droga declarado durante a colheita da prova oral (R\$ 1.000,00), a circunstância informada pelas testemunhas de que haviam notícias dando conta do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e o fato mencionado pelo acusado Douglas de que já havia comprado drogas de Chayton em outra oportunidade, constituem dados que denotam um cenário de pessoa dedicada às atividades criminosas, havendo indícios de intensa participação no tráfico de drogas. Cabe salientar que “a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida

no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'". Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5ª edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é a situação do acusado. Dessa forma, torno a pena definitiva para este crime em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo os dias-multa no mínimo legal. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, diante das particularidades do caso em comento, em especial pelo transporte intermunicipal de drogas em concurso de pessoas, bem como da existência de denúncias anteriores do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, está demonstrada a periculosidade concreta da sua conduta, razão pela qual a fixação de regime diverso do fechado não se mostra satisfatória à repressão do grave delito praticado não apenas em razão da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo, mas, notadamente, por não se tratar o réu de ínfimo e eventual traficante. Assim, fixo regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º e § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal. Diante da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Pela mesma razão, impossível a concessão da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: A) CONDENAR o acusado DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar unitário mínimo legal; e B) CONDENAR o acusado CHAYTON LUAN DE JESUS, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar unitário mínimo legal. Faculto ao acusado CHAYTON LUAN DE JESUS a interposição de recurso em liberdade, eis que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da sua prisão preventiva. O acusado DOUGLAS ADRIANO MITSUO MORITA NUNES DA SILVA não tem o direito de apelar em liberdade. Nos termos do art. 387, §1º do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, justificando-se então sua prisão como resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Ainda, considerando-se a quantidade de pena imposta nesta sentença, confirmada está a necessidade da manutenção da custódia do acusado. É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao acusado já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal. Confira-se, a respeito, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.). "HABEAS CORPUS. Tráfico de Entorpecentes. Regime inicial fechado. Fixado de acordo com a legislação vigente. Apelo em liberdade vedado

Acusado que permaneceu preso durante o processo. Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem denegada." (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.). O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5). Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do acusado, ainda mais porque lhe aplicado regime prisional de segregação rigorosa. Recomendo o acusado na prisão onde se encontra. Inaplicável o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão. Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos bens apreendidos nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06. Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada a gratuidade da justiça, que ora defiro. Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos termos do convênio. Comunicações e diligências necessárias. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Providencie-se a serventia a regularização da autuação em relação ao nome do acusado Chayton, a fim de constar Chayton Luan de Jesus. Publicada em Audiência. Cumpra-se. Saem os presentes intimados". O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. Nada mais havendo, o Meritíssimo Juiz deu por encerrada a solenidade. NADA MAIS. Eu, (Kamila Costa Luz), Escrevente Técnico Judiciário o digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotor: Defensores:

Réus: